

1501260-20.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Respondeu a processos em liberdade (tráfico). Sem vícios.

Sobre os fatos disse que não é verdade. Disse que saiu do banco e foi para o bar. Que estava com o réu bebendo e os policiais entraram no bar e começaram a revistar a bolsa. Que seu celular caiu no chão. Disse que os policiais colocaram as drogas na bolsa e a prenderam por tráfico. Disse que somente estavam quatro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501260-20.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501260-20.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176168/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25844948 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2176168 - 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYKY AUGUSTO RAMIRES GONÇALES DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

KAYKY AUGUSTO RAMIRES GONÇALVES DE SOUZA e MARIANA CAROLINE DE OLIVEIRA PROENÇA, já qualificados, foram denunciados como incursos no 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de junho de 2022, por volta das 19 horas e 30 minutos, na rotatória da Avenida Dom Aguirre com a Praça da Bandeira, centro, nesta cidade e comarca de Sorocaba, traziam consigo e guardavam para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 135 (cento e trinta e cinco) porções de Cocaína, com peso líquido de 30,83g (trinta gramas e oitenta e três centigramas); 45 (quarenta e cinco) porções de Cocaína, com peso líquido de 7,8g (sete gramas e oito centigramas); 19 (dezenove) porções de Cocaína na forma de Crack, com peso líquido de 2,96g (dois gramas e noventa e seis centigramas); 08 (oito) porções de Cocaína, com peso líquido de 1,54g (um grama e

cinquenta e quatro centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, e o laudo pericial de constatação de fls. 21/27. Consta da denúncia que, segundo o apurado, na data mencionada policiais militares receberam comunicação anônima de que um casal vendia entorpecentes na Praça da Bandeira, e ocultava a maior parte das drogas na calçada. Na posse dessas informações, os policiais diligenciaram até o local informado, visualizaram os réu, no interior de um bar defronte à praça, cujas características batiam com a descrição feita na denúncia anônima, os detiveram para a abordagem. Em revista pessoal, na bolsa que a ré trazia consigo, foram apreendidos 45 pinos de cocaína e 19 porções de crack, e o valor de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie, em notas diversas. Em poder do indiciado, em seu bolso, foram encontrados 08 pinos de cocaína, e o valor de R\$ 20,00 (vinte reais), em espécie. Em diligências pelo local, com o auxílio de um popular que apontou onde viu os indiciados escondendo os entorpecentes, foram apreendidos mais 135 porções de cocaína em um relógio d'água, localizado na mesma calçada do bar. Consta finalmente que, as circunstâncias da prisão logo após a denúncia anônima, a quantidade e natureza das drogas, de alto poder viciante, bem como a forma como os entorpecentes estavam embalados em pequenas porções, pronta para a venda, e os valores em dinheiro apreendidos, fruto do comércio ilícito, demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio. Denúncia juntada às fls. 107/111. F.A. do réu KAYKY juntada às fls. 113/114. F.A. da ré MARIANA juntada às fls. 118/120. Defesa preliminar do réu KAYKY juntada às fls. 146/149. Defesa preliminar da ré MARIANA juntada às fls. 169. A decisão de fls. 184/185, recebeu a denúncia contra os réus, designando audiência de instrução e julgamento. Laudo pericial das drogas juntado às fls. 188/190. Designada audiência de instrução e julgamento. As partes apresentaram alegações finais (fls. 257/277 - acusação, fls. 283/287 - defesa da ré MARIANA e fls. 289/299 - defesa do réu KAYKY). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Da materialidade.

A materialidade delitativa encontra-se demonstrada pelos autos de prisões em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudos periciais e demais provas.

Das autorias.

As autorias são certas.

A testemunha, Douglas do Amaral Barros (Policial Militar), informou que, se lembra da ocorrência. Que soube dos fatos por meio de denúncia anônima. Disse que no local dos fatos há comércio de drogas. A denúncia anônima indicou que um casal de jovem estava na praça praticando comércio de drogas. Informou que as características do réu que foram passadas na denúncia era que tinha luzes nos cabelos. Informou que os réus estavam na frente do bar. Que ao avistar a viatura, entraram no bar e lá foram abordados. Abordada a ré foi localizada as drogas e dinheiro na bolsa. Com o réu, foram localizadas as drogas e dinheiro no bolso. Que um indivíduo na praça, indicou o relógio de água, onde os réus guardavam outras drogas. Lá foram encontradas drogas idênticas as que estavam na bolsa da ré. Informou que não conhecia os réus. Não sabe dizer por que o popular não foi arrolado, acha que ele preferiu ficar anônimo.

A testemunha, Douglas dos Santos Sousa (Policial Militar), informou que se lembra dos fatos. Disse que, recebeu denúncia anônima acerca do tráfico. Informou que, avistou o casal, com a ré e o réu foram encontrados entorpecentes e dinheiro. Disse que localizou as drogas no relógio de água. Disse que a ré permaneceu em silêncio e não se recorda o que o réu disse. A denúncia anônima descreveu as características do réu, com sendo um indivíduo que tinha luzes nos cabelos. Disse que o local dos

fatos era uma praça. Disse que as características do réu que foi passada era que estava com os cabelos pintados de loiro. Disse que a prisão dos réus foi na frente de um bar. Informou que os réus estavam conversando de frente ao bar, quando avistados. Disse que só revistou a bolsa da ré, onde foi encontrado a droga e dinheiro. Disse que não conhecia os réus.

A testemunhas de defesa, Júlia Ramires de Oliveira Souza, informou que é irmã do réu. Informou que o réu tinha uma namorada em Indaiatuba. Que o relacionamento com o réu é bom. Que sabia que o réu era usuário de drogas.

A testemunha de defesa, Paula Cristina Gonçalves de Souza, informou que é tia do réu. Disse que convivia com o réu. Que trabalha desde os 15 anos. Tinha um jeito de usar drogas, mas não presenciou. Que o réu é solícito.

A testemunha de defesa, Jussara Maria de Souza, disse que é tia avó do réu. Informou que o réu trabalha desde 15 anos de idade com barbeiro. Disse que às vezes percebeu uma certa alteração no comportamento do réu. Não sabe se o réu tinha namorada.

O réu, KAYKY AUGUSTO RAMIRES GONÇALVES DE SOUZA, interrogado em Juízo, disse que tem 18 anos, solteiro, sem filhos, estudou até a 8ª série, barbeiro (ganha em média R\$ 800,00). Viciado em drogas (maconha e cocaína). Disse que não foi processado anteriormente. Informou que não tem passagem pela Infância.

Disse que foi na praça e comprou oito pinos para consumir e foi para o bar beber. Disse que somente descobriu a quantidade das drogas na Delegacia. Disse que não estava bebendo junto com a ré MARIANA. Informou que já é usuário há dois anos.

A ré, MARIANA CAROLINE DE OLIVEIRA PROENÇA, interrogada em Juízo disse que é solteira, tem um filho de dois anos que está com a avó. Informou que tem vinte e quatro anos. Estudou até o 2º grau do ensino médio. Ajudava o irmão na barbearia. Respondeu a processos em liberdade (tráfico). Sem vícios.

Sobre os fatos disse que não é verdade. Disse que saiu do banco e foi para o bar. Que estava com o réu bebendo e os policiais entraram no bar e começaram a revistar a bolsa. Que seu celular caiu no chão. Disse que os policiais colocaram as drogas na bolsa e a prenderam por tráfico. Disse que somente estavam quatro pessoas dentro do bar. Disse que não foi encontrada droga com ela. Somente com o réu que havia comprado para cheirar. Disse que as drogas que supostamente foram achadas, não cabiam na sua bolsa, pois era pequena. Disse e o bar não é ponto de tráfico de drogas. Disse que na Delegacia foi revistada, mas não acharam qualquer droga com ela. Disse que não conhece o traficante que vendeu as drogas para o réu. Disse que foi no banco por volta das 16 horas. Disse que quando foi abordada pelos policiais o UBER estava chegando. Disse que não perdeu a guarda do filho.

A despeito da negativa dos réus, tais versões não merecem credibilidade e exsurge isolada da prova dos autos.

Como dito pelos policiais, foram localizadas com os réus, no momento do flagrante, as drogas mencionadas na denúncia e ao depois, no relógio marcador de consumo de água, o restante dos entorpecentes, embalados de forma que demonstram o propósito da traficância.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática antes ofertada perante a autoridade policial.

Ao depois, não é crível que aludidos policiais fossem urdir sórdida e falta incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, se, de fato, fosse ele inocente.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais militares não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

São dignas de registro, a esse respeito, as ponderações do ilustre Des. Souza Nery, verbis: "Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente,

aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados." (TJSP - Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 - 9ª Câm. Crim. - Rel. Des. Souza Nery - j. 26.03.2008).

No mesmo sentido da validade do testemunho de policiais, merecem destaque alguns julgados do excelso Supremo Tribunal Federal, do colendo Superior Tribunal de Justiça e outros o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.

Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III - H.C. indeferido. (STF - HC nº 76.557-6-RJ - 2ª T. - Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Velloso - j. 04.08.1998 - DJ 02.02.2001).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC 74.608-0/SP, 1ª T., Rel. Min Celso de Mello, DJU 11/04/97).

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I - O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. II - Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III - Recurso desprovido. (STJ - RESP. nº 751.760-MG - 5ª T. - rel. Min. Gilson Dipp - j. 18.10.2005 - DJ 14.11.2005). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, C/C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368/76. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação, na medida em que a condenação se encontra devidamente motivada, com apoio no acervo probatório colhido na instrução criminal. (Precedentes). II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao depoimento de policiais. (Precedentes). III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do material cognitivo. (Precedentes). Habeas corpus denegado. (STJ - RESP. nº 34.881-SP - 5ª T. - rel. Min. Felix Fisher - j. 07.10.2004 - DJ 04.11.2004).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada. (STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. -

rel.^a Min.^a Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304).

Os testemunhos de policiais destacados para realização de repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova. (TJSP - Apel. Crim. nº 1.364.617/5-Itapecerica da Serra - 12ª Câ. Dir. Crim. - rel. Des. Luis Ganzerla - j. 10.03.2004 - V.U.).

PROVA - Testemunha - depoimentos de policial - Eficácia, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios. O policial não está legalmente impedido de depor. Assim, o valor de seu depoimento testemunhal reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. (TJSP - Rev.Crim. nº 225.988-3/0-00-São José do Rio Preto - 1º Gr. de Câ. - rel. Des. Jarbas Mazzoni - j. 23.03.1980 - RT 754/604).

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade caracterizadas pelas provas dos autos. Testemunhos de policiais que se harmonizam com os demais elementos do processo. Elevação da pena por processos sem trânsito em julgado. Impossibilidade. Violação ao princípio de presunção de inocência. Redução da pena. Acusado primário. Pequena quantidade de tóxico. Aplicação da minorante relativa ao § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, em seu grau máximo. Sursis. Impossibilidade. Aplicação do art. 44 da Lei 11.343/06. Art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, não referido pelo art. 44, que não constitui modalidade autônoma de delito, mas sim, mero benefício. Recurso provido em parte. (TJSP - Apel. Crim. nº 990.08.037267-0 - 1ª Câ. Dir. Crim. - rel. Des. Marco Nahum - j. 22.06.2009).

Torna-se imperioso, para o reconhecimento da incapacidade da prova testemunhal, exclusivamente policial, para decretar a condenação, na correta distribuição do ônus da prova, que os réus comprovassem fatos ou pontos específicos na prova positiva produzida pela acusação a demonstrar conflito ou incongruências no conjunto formado pela fala dos agentes.

Sem isto, ou seja, sem que haja contraprova àquela produzida pela acusação, seja por testemunhas civis, seja por testemunhas policiais, de se aceitar a veracidade dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial. Assim, suficiente a prova testemunhal, aliada à materialidade delitiva, para o reconhecimento da autoria do crime indicado na denúncia.

Diga-se, por oportuno, que seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosas e, quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões. São valiosas as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem.

Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade. Não parece sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício, além de ser compromissado como qualquer outra testemunha.

A autoria dos crimes em questão, assim, irrompe bem patenteada.

A forma como a droga foi encontrada no relógio medidor de água, ou seja, individualmente embaladas, conforme auto de exibição de fl. 21/27, a quantidade da droga apreendida com os réus, tudo a indicar a comercialização, além de ter ficado evidente que se voltava para abastecimento de local conhecido por ser ponto de drogas.

Noutro vértice, há de se anotar que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 não exige, para sua caracterização, a prática de ato efetivo de mercancia de drogas, tornando dispensável a prova da traditio.

É suficiente, para sua perfeita configuração, que os agentes tragam consigo, tenha em depósito ou guarde substância entorpecente.

E, no caso em apreço, está sobremaneira descortinado, à luz das provas coligidas, que os réus abasteciam local que servia como ponto de drogas e, por evidente, já estava a praticar sua comercialização.

A traficância, portanto, mostra-se segura e suficientemente comprovada. A forma como a droga apreendida estava acondicionada, a dinâmica da diligência, o relato seguro dos policiais, a circunstância de o local ser conhecido como ponto de tráfico, analisadas em conjunto, não indicam o consumo próprio e reforçam a certeza de que ocorria o tráfico.

Inviável, pois, o acolhimento da tese erigida pelas Defesas dos réus.

Presentes, portanto, autoria e materialidade do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a procedência da demanda é medida imperiosa.

Passa-se, assim, à dosimetria da pena.

Da Dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Da dosimetria da pena para o crime imputado ao réu - KAYKY AUGUSTO RAMIRES GONÇALES DE SOUZA.

Primeira fase.

a-) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal): atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, considerando-se que réu é primário e a pequena quantidade de droga, a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

Nesta fase, fixo a pena do réu em: (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Segunda fase.

b-) Circunstância legais (artigos 61, 62 e 65 do Código Penal): em segunda fase, não se apuram circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, lembrando que a menoridade relativa do réu não pode implicar redução da pena abaixo do mínimo legal aqui fixado (Súmula 231 do STJ).

Nesta fase fixo a pena do réu em: (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Terceira fase.

c-) Causas de aumento e diminuição de pena: reconhecimento, em terceira fase, à luz da

constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena. O réu é primário, não possui antecedentes criminais. Não há elementos probatórios robustos e altaneiros capazes de indicar que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, a pena deve ser deduzida no patamar de 2/3. Nesta fase, fixo a pena definitiva do réu em: (01) ano e (08) meses de reclusão e pagamento de (166) dias-multa, no valor unitário.

Do valor dos dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Do regime prisional.

Dessa forma, considerando o total de pena imposta, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Insta sondar, em seguida, sobre a possibilidade ou não de a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos.

O excelso Supremo Tribunal Federal, por seu órgão Pleno, no julgamento do HC 97.256-RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto, ocorrido em 1º de setembro de 2010, reconheceu, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §4º do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei nº 11.343/06, no que se refere à proibição da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por compreender que a vedação, em síntese, vulnera o princípio da individualização da pena.

A Corte Constitucional, portanto, decidiu ser possível a substituição da pena carcerária pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Esse entendimento foi reafirmado em julgamentos posteriores (HC 102.351-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.423-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 101.205-RS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, todos julgados em 21/09/2010).

A partir da orientação sedimentada no seio do Supremo Tribunal Federal, respeitadas posições em contrário, há de se privilegiar o princípio constitucional e o direito individual fundamental da segurança jurídica, cujo corolário principal assenta-se no primado da previsibilidade das decisões judiciais.

Há de se homenagear, ainda, o princípio constitucional e o direito individual fundamental da isonomia, porquanto não soa razoável, tampouco justo e jurídico, que situações idênticas ou semelhantes, em idêntica ou semelhante condição pessoal do réu, sejam resolvidas de forma distinta.

O compromisso do julgador com a segurança jurídica, com a previsibilidade das decisões judiciais, e com a preservação da isonomia, sempre respeitadas primorosas opiniões dissidentes, o impele a renunciar à interpretação que, pessoalmente, possua sobre o acerto ou o desacerto do entendimento consolidado no seio do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em baila.

Plantada a premissa da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, passa-se a analisar, neste caso concreto, se o réu preenche ou não os requisitos alinhavados no art. 44 do Código Penal.

E a resposta, antecipe-se, é positiva.

As circunstâncias judiciais não desfavorecem o réu, que foi encontrado com uma quantidade não expressiva de droga apreendida, é primário, bons antecedentes, associado à falta de prova de se dedicar às atividades criminosas ou de integrar organização criminosa.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de

direito, consubstanciadas em: (i) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (ii) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).
As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não subsistem os pressupostos e requisitos legais que ensejaram a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime aberto.
Expeça-se Alvará de Soltura, com urgência.

Da dosimetria da pena imputada à ré - Mariana Caroline de Oliveira Proença.

Primeira fase.

a-) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal): atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, embora a ré ostente condenações anteriores pelo art. 33, caput da Lei de Drogas (autos n. 1500435-18/2018, 1503480-85/2019 e 1500435-18/2018), fixo a pena no mínimo legal, já que a reincidência será valorada na segunda fase.

Nesta fase, fixo a pena da ré em: (05) anos de reclusão e pagamento de (500) dias-multa.

Segunda fase.

b-) Circunstância legais (artigos 61, 62 e 65 do Código Penal): em segunda fase, verifico que a ré é reincidente específica devendo a pena ser majorada no patamar de 1/6.

Nesta fase, fixo a pena da ré em: (05) anos e (10) meses de reclusão e pagamento de (583) dias-multa.

Terceira fase.

c-) Causas de aumento e diminuição de pena: deixo de aplicar o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que a ré é reincidente específica.

Nesta fase, fixo a pena definitiva em: (05) anos e (10) meses de reclusão e pagamento de (583) dias-multa, no valor unitário.

Do valor dos dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Do regime prisional.

Dessa forma, considerando o total de pena imposta, fixa-se o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade da ré por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP).

No que toca à acusada MARIANA, que alega ter um filho menor de 12 anos de idade, é o caso de indeferimento do benefício pleiteado pela defesa.

Não há nos autos, qualquer documentação acerca da maternidade alegada pela ré (certidão de nascimento).

Também não há, qualquer documento comprovando que a ré seja a única com possibilidade de cuidar do menor. Ademais, seu filho, está sob os cuidados da avó, conforme declaração da própria ré, desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Por essas razões, indefiro o pedido de conversão da prisão em domiciliar.

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 (reincidência específica) do Código Penal, não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Por este processo, a ré vem respondendo o crime presa. Deixo de conceder à condenada o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade, porque além de ser reincidente, respondeu a todo o processo presa, e assim devendo permanecer, ainda mais agora diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivo.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR os acusados:

a-) KAYKY AUGUSTO RAMIRES GONÇALES DE SOUZA, como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de (01) ano e (08) meses de reclusão e pagamento de (166) dias-multa, no valor unitário, no regime inicial de cumprimento de pena ABERTO. A pena privativa de liberdade imposta será substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (i) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (ii) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal). As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais. Expeça-se alvará de soltura.

b-) MARIANA CAROLINE DE OLIVEIRA PROENÇA, como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena de (05) anos e (10) meses de reclusão e pagamento de (583) dias-multa, no valor unitário em regime inicial FECHADO. Recomende-se a ré na prisão onde se encontra.

Do perdimento dos bens e valores apreendidos.

Decreto ainda o perdimento dos bens e valores apreendidos com o réu, em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei nº 11.343/06.

Da sucumbência

Sucumbentes, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a eles se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, considerando-se que a ré MARIANA está assistida pela Defensoria Pública. Quanto ao réu KAYKY, tudo indica suas insuficiências de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA